

1513700-95.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEAN CARLOS CARVALHO DA MOTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

JEAN CARLOS CARVALHO DA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513700-95.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513700-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEAN CARLOS CARVALHO DA MOTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

JEAN CARLOS CARVALHO DA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 10 de junho de 2022, por volta das 17h21min, na Rua Cereja do Rio Grande, nº 32, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico :

219 porções de cocaína, pesando 114,4 gramas;

41 porções de cocaína na forma de crack, pesando 6,7 gramas;

149 porções de maconha, pesando 256,8 gramas;

5 porções de haxixe, pesando 0,01 gramas;

11 porções com substância ainda não identificada, pesando 5,3 gramas, supostamente "LSD";

5 porções com substância ainda não identificada, pesando 0,2 gramas, supostamente "ecstasy", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55, da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensor constituído nos autos (págs. 84/88).

Recebida a denúncia (págs. 98/100), foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou a absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereu: pena fixada no mínimo legal; regime de cumprimento diverso do fechado; e, por fim, seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do tráfico de drogas veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); auto de exibição e apreensão (págs. 12/13); boletim de ocorrência (págs. 20/23); pelo laudo de constatação (págs. 24/28); pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 72/76), que resultou positivo para cocaína, Tetra-hidrocanabinol e metilenodioximetanfetamina (MDMA); e pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento do crime.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, declarou que: "(...) era foragida pelo crime de roubo e que quando viu os policiais militares tentou correr por esse motivo e não porque estava vendendo drogas. Nisso, nega que estava traficando drogas e só fugiu porque era foragido." (pág. 11).

Em juízo, já sob o crivo do contraditório, esclareceu que é usuário e viciado no consumo de maconha. Disse que à época estava trabalhando com sua esposa, vendendo doces. Portava uma nota de R\$200,00, oriunda do seu trabalho, e se dirigiu ao local em que foi preso para adquirir duas porções da droga. O traficante correu logo depois que entregou a ele o dinheiro para pagamento das porções de maconha que estava adquirindo, oportunidade em que notou a aproximação policial.

Acrescentou que registra condenação anterior, com mandado de prisão em aberto, de forma que correu atrás do traficante, por cima de um muro, o que fez porque sabia que era procurado pela justiça. Entretanto, acabou caindo e acordou na viatura policial.

Por fim, disse que não portava qualquer sacola, negando qualquer responsabilidade pelas drogas apreendidas.

Referida exculpatória, contudo, além de previsível e bem pouco consistente, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa - notadamente pelo firme relato das testemunhas inquiridas, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

Os policiais responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram esclarecimentos consistentes e narraram como se desenrolou a prisão em flagrante do acusado.

Esclareceram que patrulhavam pelo local, viram dois rapazes em um condomínio, que notaram a guarnição e puseram-se em fuga. Nesse momento estava entrando um morador, que abriu o portão, de forma que ingressaram no referido condomínio e nos fundos visualizaram os dois indivíduos em cima de um muro. Quando notaram a guarnição os dois se jogaram. Deram a volta com a viatura e encontraram o acusado desmaiado no chão, em virtude da queda, e havia uma bolsa ao lado dele. O outro indivíduo conseguiu fugir.

No interior da bolsa que estava ao lado do acusado havia várias porções de drogas e uma quantia em dinheiro.

O acusado admitiu que estava vendendo drogas, que estava há poucos dias no local, e "... confessou que estava lá vendendo, que começou há poucos dias, que realmente estava trabalhando lá, que lá eles chamam de loja, mas o movimento estava fraco, que tinha nascido o filho dele...".

Como consignado, a prova produzida no contraditório bem demonstrou a ocorrência do delito, sendo incontroversa a autoria.

Nas ocasiões em que foi interrogado, o acusado negou o cometimento do crime, tentando fazer crer que estava no local dos fatos para comprar drogas, que não chegou a adquirir, dispunha da quantia de R\$200,00 fruto de seu trabalho com sua esposa, e apenas correu do local quando avistou a aproximação policial em razão de já ter sido condenado anteriormente.

Entretanto, essa singela negativa de autoria não é merecedora de nenhuma credibilidade, uma vez que nem de longe foi comprovada pela Defesa, como lhe competia, nos termos do que prevê o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Aliás, acatar a inconsistente versão do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

No caso em apreço, o réu foi surpreendido carregando uma sacola contendo inúmeras e diversificadas porções de substâncias entorpecentes (cocaína, maconha, crack, haxixe e MDMA). No momento em que percebeu a aproximação dos policiais, empreendeu fuga através de um muro, de onde se jogou, e acabou caindo.

E os policiais ouvidos, de forma bastante serena e insuspeita deram conta da diligência que realizaram e que culminou a prisão do acusado portando uma sacola contendo as drogas referidas na denúncia.

Vale consignar que os esclarecimentos apresentados pelos policiais são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

O acusado portava drogas fracionadas e diversificadas, em quantidade incompatível com a posse para mero consumo, ou seja, 219 porções de cocaína, 41 porções de cocaína na forma de crack, 149 porções de maconha, 5 porções de haxixe e 11 porções de MDMA.

Ademais, as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto a finalidade das drogas, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei especial.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei

6.368/76." (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

Por fim, questionado pelos policiais, informalmente, o acusado admitiu que estava vendendo drogas naquele local - "loja" -, o que já vinha fazendo há alguns dias, justificando dificuldades financeiras.

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a autoria, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão juntada às págs. 66/67 dá conta de uma condenação definitiva suportada pelo réu, pela prática de crime de roubo, oriunda de processo que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Capital, cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 19/11/2021, que configura reincidência.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu. O artigo 42 da Lei 11.343/06, que prepondera sobre critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, determina que, na fixação da pena, deverão ser consideradas a natureza e a quantidade das substâncias, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em apreço, como dito, o réu foi trazia consigo expressiva quantidade de drogas – separadas por 219 porções de cocaína, 41 porções de cocaína na forma de crack, 149 porções de maconha, 5 porções de haxixe e 11 porções de MDMA – entorpecentes suficientes para servir inúmeros usuários, o que compromete sobremaneira a saúde pública. Ademais, boa parte cocaína e crack, substâncias altamente nocivas e viciantes, a denotar que se dedicava à atividade criminosa em questão, não sendo esse um fato isolado em sua vida.

Por esses argumentos, pela quantidade expressiva de drogas diversificadas encontradas em poder do acusado, o que revela intensidade do dolo, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Por fim, pela reincidência comprovada, agravo a pena em mais 1/6, tornando-a definitiva em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Pelas razões consignadas quando da fixação da pena-base, bem como pela comprovada reincidência, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito a dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade.

Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC

111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido." (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JEAN CARLOS CARVALHO DA MOTA, R.G. nº 38.969.104, e o condeno ao cumprimento de sete anos de reclusão e ao pagamento do valor setecentos dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista a reincidência comprovada, bem como o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Considerando-se que o crime aqui tratado é considerado hediondo, também por força da agravante da reincidência, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e igualmente não preenche os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que mostram-se presentes os fundamentos que justificaram a medida, reforçados pela prova produzida no contraditório, o que se faz necessário também para se assegurar a aplicação da lei penal com o cumprimento da pena aqui aplicada (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Eventual progressão de regime de cumprimento de pena é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06, e artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro relacionada no auto de exibição e apreensão - R\$195,00 - , uma vez oriunda do comércio ilícito de drogas.

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA